

1500863-95.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... para aumentar a pena-base e, também, afastar o tráfico privilegiado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIPO POR VIOLADO, QUANTO A UMA DAS TESES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500863-95.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500863-95.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2239533/2019 - DEL.POL.APARECIDA, 6899101 - DEL.POL.APARECIDA, 2295/19/201 - DEL.POL.APARECIDA, 2239533 - DEL.POL.POTIM, 2295/19/201 - DEL.POL.POTIM, 2239533 - DEL.POL.POTIM, 2295/19/201 - DEL.POL.POTIM

Autor:

Justiça Pública

Réu, Averiguado e Indiciado:

PAULO CESAR RIBEIRO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O Ministério Público denunciou PAULO CESAR REIBEIRO como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, sob alegação de que: "no dia 18 de agosto de 2019, por volta das 13h20, no interior de uma residência situada na Rua Nossa Senhora Aparecida, numeral 116, Bairro Vista Alegre, Potim, nesta Comarca, PAULO CESAR RIBEIRO, qualificado às fls. 6, guardava e tinha em depósito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devidamente apreendidas (fls. 16/18) e constatadas (fls. 22/24)." (fls. 87/88). Em análise do flagrante, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 33/35).

A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2019 (fls. 90/91).

Folha de Antecedentes às fls. 114/115.

Decisão mantendo a prisão preventiva (fls. 133/134).

O réu apresentou resposta à acusação às fls. 135/139.

Manifestação do Ministério Público às fls. 145/146.

Decisão mantendo a prisão preventiva (fls. 151/152).

Decisão revogando a prisão preventiva (fls. 195/197).

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 18 de maio de 2022 (fls. 254/255) colheu-se o depoimento da testemunha Claudinei e determinou-se a designação de audiência em continuação.

Em continuação (25 de agosto de 2022) foi ouvidas a testemunha Marcos Paulo de Oliveira, a testemunha de defesa Rosa da Conceição Pereira e, ao final, interrogado o réu.

As partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, nos exatos termos em que formulada.

Em alegações finais, a defesa pugnou pela absolvição do acusado, sustentando que as drogas não pertenciam ao acusado. Narrou que as anotações de fls. 55/68 indicam que a contabilidade se referia a sua profissão de gesseiro. No mais, sustentou que a droga não foi encontrada na posse do acusado e por isso não pode ser considerada como de sua propriedade. Ao final, sustentou a improcedência da inicial acusatória. Vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A pretensão punitiva é procedente.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo do topo do art. 33 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A materialidade delitiva resultou provada pelo Termo de Depoimento de Claudinei Bittencourt da Silva (fls. 03/04), Termo de Depoimento de Marcos Paulo de Oliveira (fl. 05), Termo de Interrogatório Auto de Prisão em Flagrante (fl. 06), Boletim de Ocorrência (fls. 11/15), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 16/18), Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Relatório Final (fls. 82/83), Laudo Pericial (fls. 22/25), especialmente pelo Laudo Químico-Toxicológico definitivo (fls. 119/121), bem como pela prova oral colhida.

No mais, é certa a autoria.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, policial militar Claudinei Bittencourt da Silva, declarou em juízo que:

Que na data dos fatos, estava com o companheiro de serviço. Estava em patrulhamento na região. Abordaram uma pessoa que se encontrava em atitude suspeita. Ao ver a viatura, ele tentou fugir. Com ele foi encontrado um celular, dinheiro e entorpecente. Quando indagado, o abordado disse que realmente estava vendendo entorpecente e que buscava mais droga em potim. Indicou o endereço do local. Fizeram contato com o morador da residência que autorizou a entrada no local. Fizeram uma vistoria. Em cima de um micro-ondas, localizaram mais entorpecente, caderno, dinheiro, faca e utensílios para fracionar a droga lá encontrada, dentro e uma mochila. Havia mais 2 menores na residência. O abordado, um adolescente, não

falou que lembrava do nome da pessoa que estava lá. No local, o abordado informou quem seria o dono do local. O portão estava entreaberto e o réu autorizou a entrada na residência. Não conhecia nenhum dos envolvidos. no caderno encontrado, não se lembra o que estava escrito.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, policial militar Marcos Paulo de Oliveira, declarou em juízo que:

Que na data dos fatos, abordaram um jovem com drogas e ele apontou onde estavam as outras drogas. Que foram até o local indicado. Que nesse local encontraram os entorpecentes.

Que além das drogas encontraram diversos petrechos para embalar a droga. Que esses objetos estavam na cozinha. Que havia três pessoas no local. Que os três estavam mexendo com as drogas. Que os outros estavam na cozinha, manuseando uma pequena porção da droga, além de faca, papel e embalagens. Que o restante da droga estava em uma sacola. Que estava em quarto, junto com um monte de roupa. Que não chegou a conversar com o réu. Que os dois jovens disseram que não tinham nada a ver com a droga. Que o denunciado Paulo César, pai dos dois jovens que estavam no local, assumiu a propriedade da droga e disse que estava guardando para uma terceira pessoa.

Que a droga foi encontrada no interior da residência. Que encontraram um caderno de contabilidade, mas não se recorda exatamente o que estava escrito.

Cumprе salientar que às fls. 254 decretou-se a revelia do acusado, razão pela qual não foi interrogado.

Cumprе salientar que, a despeito das alegações da defesa, os dois policiais militares, quando ouvidos em juízo sob compromisso de dizer a verdade, narraram, sem deixar qualquer dúvida e em total coesão e harmonia, que o réu Paulo César Ribeiro foi localizado na posse das substâncias entorpecentes apreendidas e periciadas. Inclusive, relataram que o réu confessou informalmente que estaria guardando a droga para uma terceira pessoa.

No tocante à idoneidade de depoimentos de Policiais Militares, mister ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Nesta senda:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,

age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos ." (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97, p. 12.189, in TACRIM - As mais recentes decisões nº 5, Jun/97, p.07

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Portanto, a prova trazida pelos policiais tem o condão de conduzir a condenação dos acusados, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e sequenciais, além de trazerem detalhes a respeito dos fatos ora apurados. Ademais, não há que se falar em contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação, uma vez que não entraram em contradição em momento algum.

Além disso, é esse o entendimento dos Tribunais:

"Pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboçar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias nos pontos secundários que são frutos da imperfeição do psiquismo humano" (JUTACRIM, vol. 95/26, rel. Segurado Braz).

"O importante é como nos diz DELLAPIANE, verificar se embora descorando dos detalhes mínimos concorra a final nos pontos essenciais, nas circunstâncias mais importantes do fato que cada uma, isoladamente reconstituiu" (Nova Teoria da Prova - 2ª ed., Ed. Konfino, 1958 - pág. 145).

Ora, como se vê, a versão trazida pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado é lógica e coesa, não trazendo quaisquer elementos que a ponham em cheque. Assim, nada há que se discutir quanto à forma como se deram os fatos.

Ambas as testemunhas confirmaram, de modo coerente e lógico, confirmaram que o réu estava na posse das substâncias e materiais apreendidos.

Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice.

Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos, sobretudo as confissões espontâneas dos acusados em juízo.

A prova produzida nos autos é segura e conclusiva, sendo apta a autorizar o decreto condenatório.

Dá-se o crime de tráfico ilícito de drogas quando o agente pratica um dos núcleos do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a realização de um único verbo do tipo para a adequação da conduta.

No caso dos autos, o réu trazia, guardava e tinha em depósito para a entrega ilícita ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes (cocaína) que causam dependência física e psíquica, para entrega a consumo de terceiro.

Analisados os aspectos referidos, que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, é evidente que a droga encontrada destinava-se ao tráfico, mormente pela quantidade encontrada, pelo local e circunstâncias da apreensão, bem como pela forma de acondicionamento, incompatível com o mero usuário.

Cabe citar que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer uma das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse

mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos. (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJ e 01/07/2016)

Nesse sentido, a jurisprudência:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga, comportamento do representado logo antes ou no momento da apreensão, a existência de outros elementos referentes à venda, etc.

Nesta senda:

"A natureza altamente lesiva e a quantidade de porções da droga capturada, somadas à apreensão de apetrechos geralmente utilizados no preparo e disseminação de tóxicos, bem como de certa quantia em dinheiro, são fatores que indicam envolvimento maior com a traficância, autorizando à preventiva." (HC 323.748/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, REPDJ e 05/10/2015, DJ e 28/09/2015).

Quanto ao destino das drogas apreendidas, não se discute que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao nefando tráfico. A natureza da drogas apreendidas, a maneira como estavam acondicionadas, bem como a as condições de tempo e lugar em que os acusados foram abordados, além das declarações dos policiais, denunciam o referido comércio.

Soma-se a isso os materiais que foram apreendidos com o acusado, quais sejam, a balança de precisão, bem com os papérols de alumínio, petrechos esses comumente utilizados para a preparação das drogas para venda.

Portanto, o acusado realizou conduta típica, antijurídica e punível, em face de sua culpabilidade, impõem-se a condenação e a pena, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Logo, presentes todos elementos normativo do tipo penal inscrito no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que a culpabilidade não ultrapassou a esfera de normalidade ao tipo penal; o réu é primário; não há elementos seguros para valorar a conduta social do réu; tampouco a personalidade do agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do Juiz; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo; e não há comportamento da vítima relevante para valorar. A quantidade de droga é elevada o suficiente para aumento da pena-base, sendo certo que a gravidade abstrata do delito já foi considerada pelo legislador ao fixar as penas mínima e máxima. Assim, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Em seguida, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Na terceira fase, a prova dos autos é suficiente para concluir, seguramente, que ele se dedica à prática reiterada do tráfico ilícito de drogas. É certo que a Nova Lei de Drogas aperfeiçoou a sanção penal ao operar a distinção entre meros mercadores ocasionais, também merecedores de atenção do Estado, dos comerciantes de droga mais estruturados, verdadeiros empresários do tráfico. Distinção reclamada há muito tempo pelos aplicadores do Direito, tem por consequência a menor reprovabilidade da conduta do traficante ocasional e sua pena encontra fundamento e limite com a redução a integrar o tipo penal para os que apresentem as condições subjetivas típicas daqueles que não tenham estruturado envolvimento com o tráfico de drogas.

No presente caso, entendo não ser cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, justamente por considerar as circunstâncias do caso concreto, especial a grande quantidade de entorpecente apreendida em poder do sentenciado (peso líquido de quase 2kg de cocaína), conforme laudo de constatação preliminar de fls. 23/25. Para se ter uma ideia, um "pino" de cocaína possui em média de 0,5g a 1,5g da droga. Ou seja, a quantidade de entorpecente apreendida em poder do acusado serviria para divisão em cerca 2 (dois) mil "pinos". Não bastasse esse montante elevadíssimo de entorpecentes apreendidos, ainda em poder do acusado foram encontrados petrechos que são comumente utilizados por traficantes habituais, tais como balanças de precisão, rolos de papel filme e papel alumínio, celulares diversos, caderno com anotações de contabilidade do tráfico.

Tais circunstâncias trazem o juízo de certeza que o sentenciado, a despeito de sua primariedade, faz do tráfico de drogas seu meio de vida, se dedicando a atividades criminosas de forma habitual.

Os requisitos previstos no art. 33, §4º, quais sejam primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa são CUMULATIVOS, de modo que para o acusado fazer jus a tal causa de diminuição de pena, devem estar presente todos os requisitos, o que não é o caso do sentenciado, uma vez que se dedica a atividades criminosas.

A respeito da possibilidade de a quantidade e variedade de drogas ser avaliada para aumentar a pena-base e, também, afastar o tráfico privilegiado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIPO POR VIOLADO, QUANTO A UMA DAS TESES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR.

POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NOS DOIS DELITOS, PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE, TAMBÉM NOS DOIS CRIMES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INFRAÇÕES DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...) 4. É permitido valorar a natureza e a quantidade da droga negativamente na primeira-fase da dosimetria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem que isto configure bis in idem. (...) 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido" (AgRg no REsp 1675656/RS 5ª Turma do STJ Rel. Min. Ribeiro Dantas j. 09/3/2021).

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADA PELO TRIBUNAL LOCAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.

IDONEIDADE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE AO PACIENTE LEANDRO. PRETENSÃO RECHAÇADA PELA INSTÂNCIA A QUO. ALTERAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.

CONVICÇÃO DA CORTE LOCAL QUE O PACIENTE EXERCIA A TRAFICÂNCIA DE FORMA HABITUAL.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) VIII - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de

redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade, na diversidade e na natureza da droga apreendida, ou seja: 48 g de cocaína; 35,5 g de crack; e 155 g de maconha. Assim, a Corte originária se convenceu de que os pacientes se dedicavam, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficantes ocasionais. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 627596/SP 5ª Turma do STJ Rel. Min. Felix Fischer j. 02/3/2021). Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, torno-as de definitiva nesse montante.

Consoante a pena aplicada, sendo o réu primário, fixo o regime SEMIABERTO, para início de cumprimento de pena, consoante art. 33, §2º, do Código Penal.

O valor do dia multa vai no mínimo legal.

Pelo montante de pena aplicada, inviável a substituição da pena e a concessão de sursis, na forma dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Assim, a sanção fica definida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, sendo o valor do dia-multa o piso mínimo legal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de suspensão condicional da pena, em razão da quantidade da pena aplicada.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu, PAULO CESAR RIBEIRO, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Tendo respondido ao processo em liberdade e na ausência de pedido expresso da acusação, remanesce hígido o direito do acusado de recorrer também em liberdade (artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal).

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, determino o perdimento dos valores apreendidos (fl. 103), em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva guia de execução, oficie-se ao TRE para fins de suspensão dos direitos políticos, expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo e, oportunamente, arquivem-se.

Taxa judiciária, pelo réu.

Aparecida, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA